



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0065448-08.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **KEVIN MARTINS PALMEIRA DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Richard Francisco Chequini**

VISTOS

KEVIN MARTINS PALMEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos cumulados com artigo 40, inciso III e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque , como a narra a denúncia, no dia 04 de agosto de 2016, por volta das 09h50min, na Rua Majer Kucinski, n.º 584, próximo à Escola Estadual Professora Maud Sá de Miranda Monteiro, Jardim Comercial, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de Capital/SP, agindo em concurso, caracterizado pelo vínculo subjetivo e unidade de desígnios com **LUCAS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO BATISTA**, trazia consigo, para entrega e comercialização a terceiras pessoas, aproximadamente 112,8g (cento e doze gramas e oito decigramas) de cocaína, acondicionados em 113 (cento e treze) microtubos plásticos, tipo “eppendorf”, aproximadamente 17,5g (dezessete gramas e cinco decigramas) de cocaína, na forma de “crack”, acondicionados em 46 (quarenta e seis) invólucros plásticos, aproximadamente 135, 7g (cento e trinta e cinco gramas e sete decigramas) da droga Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida por “maconha”, acondicionados em 65 (sessenta e cinco) invólucros plásticos, e aproximadamente 0,4 g (quatro decigramas) de 3,4-Metilenodioximetamfetamina (MDMA), popularmente conhecida por “Ecstasy”, acondicionados em 02 (dois) invólucros plásticos, fazendo-o sem autorização ou em desacordo com determinação

0065448-08.2016.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

legal ou regulamentar.

Também constam nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, **KEVIN MARTINS PALMEIRA DA SILVA**, já qualificado associou-se com o adolescente **LUCAS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO BATISTA**, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, próximo a Escola Estadual Professora Maud Sá de Miranda Monteiro, o crime de tráfico de entorpecentes acima descritos.

O denunciado foi notificado¹ e apresentou defesa². Houve o recebimento da denúncia³. Seguiu-se citação.

Em instrução foram ouvidas testemunhas de acusação e outra de defesa. Interrogado, o acusado o acusado negou a imputação. Nos debates, o Ministério Público postulou a parcial procedência da ação, enquanto a Defesa se debateu por absolvição, em vista da prova produzida, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, **DECIDO**.

Denúncia **PARCIALMENTE PROCEDENTE**.

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos⁴.

Consta dos autos que, na data dos fatos, o acusado junto com o

¹ Fl. 223

² Fl. 225/227

³ Fl. 234

⁴ Fls. 267/269;

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

adolescente Lucas associaram-se para a prática de tráfico de drogas, próximo a Escola Estadual Professora Maud Sá de Miranda Monteiro. Assim, ambos estavam no local dos fatos quando foram abordados por policiais militares que realizavam patrulhamento a procura do menor, que era evadido da Fundação Casa. Realizada a revista pessoal, encontrou-se com o acusado as drogas acima discriminadas e com o menor Lucas a quantia de R\$ 27,00 (vinte e sete reais).

O policial Fábio Ramazzotti Soliano, policial militar, declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento junto com o Soldado Diego, atendendo denúncia a qual informava a localização do menor Lucas, que encontrava-se evadido da Fundação Casa; assim, direcionaram-se a Rua Majer Kucinski.

Ao chegarem ao local, avistaram o adolescente Lucas conversando com o acusado, em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, embora perto da Escola Estadual Maud de Sá, encostados num muro.

As drogas apreendidas estavam numa pochete, dispensada por Kevin, momentos antes da apreensão.

Em relação ao adolescente Lucas, sua identidade restou confirmada, bem como foi encontrado, em sede de revista pessoal, a quantia de R\$ 27,00 (vinte e sete reais), enquanto com o acusado, foi localizada sob sua blusa uma pochete, contendo substâncias que aparentavam ser entorpecentes, bem como um aparelho celular sobre qual o acusado não soube declinar a procedência.

Lucas servia como “olheiro”, sendo que já havia sido detido várias vezes anteriores, sempre por tráfico de entorpecentes.

O local onde estavam era próximo de um colégio, e não foi



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

presenciada por nenhuma outra pessoa a ação em que resultou a prisão do acusado.

Não conhecia Kevin, apenas Lucas, já detido outras duas vezes por tráfico de entorpecentes.

Após a testemunha visualizar o mapa de fl. 281 dos autos, afirma a testemunha que a numeração do local, da via pública, é toda irregular, sendo certo que o local onde praticado o tráfico fica, exatamente, nos fundos da escola indicada na denúncia.

O policial militar Diego dos Santos Moraes disse que avistaram réu e menor no local indicado. Lucas, evadido da Fundação Casa, estava sendo procurado. Com Kevin foi encontrada uma bolsa contendo entorpecentes e dinheiro. Ele disse que, realmente, estava na traficância, juntamente com o menor Lucas. Trata-se, efetivamente, de local conhecido pela prática da traficância. O local da abordagem fica próximo ao um conjunto do CDHU, situando-se a 50 ou 60 metros de uma escola estadual. Inicialmente abordaram Kevin e Lucas se evadiu, sendo detido posteriormente, escondido atrás de “barracos existentes no local”. O próprio Kevin indicou onde poderiam encontrar Lucas porque, segundo ele, era naquele local onde costumavam se homiziar quando havia incursão policial.

A testemunha Carlos Alberto de Freitas declarou que o acusado é seu empregado, assistente de produção, em sua produtora de vídeo. No dia da prisão de Kevin, ele esteve em sua residência, na parte da manhã. Pediu que fosse a uma padaria, por volta das 09:00 horas da manhã. Não voltou porque foi preso. Não sabe dizer da conduta anterior do acusado, antes de ser admitido na sua empresa. Conhece a escola estadual Maud Saud Miranda. De seu escritório até a escola dista 500 metros, não mais. A padaria a qual ele, réu, deveria ir, fica próximo à escola. Para ir até a padaria, não é necessário passar pela escola referida. A padaria onde Kevin deveria ir fica em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quarteirão paralelo àquele onde localizado sua produtora, e bastante distante da escola estadual. Não sabe dizer, portanto, porque Kevin foi detido nas proximidades de tal estabelecimento de ensino.

Interrogado, o acusado declarou que não tinha nenhuma droga consigo. Afirma que Lucas já estava detido quando houve a abordagem policial. Segundo afirma, já era conhecido do policial Fábio, com tinha sérios enteveros. Nega estivesse em posse de qualquer entorpecente.

Foi o que se colheu da prova, tornando certas autoria e materialidade delitivas.

A alegação comum da defesa, de ser necessária a exclusão dos depoimentos de testemunhas, por serem policiais, não procede.

O policial, agindo dentro de sua função pública, goza da presunção *juris tantum* de agir escorreitamente, presumindo-se ser legítima a sua atuação, sendo certo que como qualquer pessoa, pode ser testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade. Até mesmo porque o policial *“deve no exercício das funções (e depor sobre suas ações constitui parte de seu mister) igualmente dizer a verdade, só não merecendo consideração se os indícios constantes dos autos o contrário revelem...”*⁵.

Por estes motivos a simples condição de policial, conforme reconhece a Suprema Corte⁶, não torna a testemunha impedida ou suspeita.

Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em

⁵ TJSP – Ap. Crim. 177.083-3/6.

⁶ RTJ 68/64.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusar o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem para sua suspeição, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende.

Sendo, portanto, o depoimento policial plenamente válido, não podendo ser, aprioristicamente, desconsiderados em razão da condição de policial, máxime quando não contraditados em Juízo⁷, o que serve de indício da lisura de sua atuação, afasta-se a alegação de falta de validade.

Por outro lado, a indisposição pretérita que haveria entre o réu e o policial Fábio não restou minimamente demonstrada.

Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público, ainda se houve qualquer indisposição entre o menor e o policial, assim também não haveria porque acusar injustamente o ora réu.

Por outro lado, a própria assertiva do acusado, no sentido de que estava apenas comprando pão para seu patrão, a testemunha Carlos Alberto, restou invalidada pelo depoimento de Carlos.

Isso porque, após visualizar o mapa indicado em fl. 281 dos autos (fornecido pela Defesa), a própria testemunha afirmou que, em relação à sua produtora de vídeo e, também, em relação à padaria, há muita distância do local onde sitiada a escola estadual, proximidades da qual foi preso o ora acusado.

⁷STJ : De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013). (HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em outros termos: não havia motivo qualquer para que Kevin estivesse naquele local, próprio da traficância, como afirmaram e reafirmaram os policiais militares nesta solenidade ouvidos.

Por outro lado, como hoje visto, também enquanto trabalhava para a testemunha Carlos Alberto, o ora réu viu-se envolvido em novo fato criminoso (receptação), o que indica que, por si só, o fato de estar em trabalho fixo, não o impediu de praticar crimes.

Em relação a causa de aumento, o que o artigo 40, inciso III, da Lei de regência visa coibir é, exatamente, a maior facilidade de propagação das drogas por conta de maior afluxo de pessoas aos locais taxativamente indicados. “Visa-se, com ele, proteger principalmente a incolumidade pública, dado o maior número de pessoas presentes”, como lembram Delmanto et al.^{8 - 9}.

Por outro lado, a lei não exige que tais estabelecimentos sejam especialmente visados pelos delinquentes, bastando, para tanto, a proximidade física e o conhecimento de tal circunstância pelo traficante¹⁰.

Finalmente, deve-se verificar que “o termo imediações não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem”, como lembra VICENTE GRECO FILHO¹¹.

⁸ DELMANTO, R. et al., “Leis Penais Especiais Comentadas”, 2ª ed., 2014, Ed. Saraiva, pág. 970.

⁹ Entendimento firme do C. STF: HC 122.701 e HC 118.767, ambos da 1ª Turma.

¹⁰ GRECO, V. “Tóxicos. Prevenção. Repressão” 14ª ed., 2011, Ed. Saraiva, pág. 232. No mesmo sentido, DAMÁSIO JESUS, “Lei Antidrogas Anotada”, 10ª ed., 2010, Ed. Saraiva, p. 226.

¹¹ Op. cit., p. 232.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Não procede, por outro lado, a imputação do artigo 40, inciso VI, relativamente à participação do adolescente Lucas, na medida em que não comprovada qualquer associação com tal inimputável. Deveras, eventual prática de ato infracional equivalente ao tráfico de entorpecentes, por Lucas, não é suficiente para fazer prova que estivesse, na oportunidade, em atividade ilícita na companhia do réu.

De se salientar, ainda, que Lucas restou absolvido quanto à imputação de tráfico, perante a Vara Especializada, conforme sentença copiada em fls. 199 e seguintes dos autos.

Artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Neste ponto a denúncia também não procedente.

Não comprovada de forma cabal a prévia e duradoura associação para o tráfico de entorpecentes, não pode ser imposta condenação, mormente quando baseada apenas em conjecturas¹². Isso porque, “três são os requisitos básicos: um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a concretização de um programa delinquencial”¹³.

Entendimento esse conforme, inclusive, àquele do C. STJ¹⁴.

Não houve diligência policial suficiente para estabelecer o vínculo

¹² **TJSP**, 11ª C.Crim., rel. Des. ABEN-ATHAR, Ap. 0364594-04.2010, j. 15 de junho de 2011. No mesmo sentido, 5ª C.Crim, rel. Des. PINHEIRO FRANCO, Ap. 993.08.040835-1, j. 31 de julho de 2007.

¹³ ALBERTO SILVA FRANCO, apud DAMÁSIO E. JESUS, “Lei Antidrogas Anotada”, 10ª ed., 2010, p. 177.

¹⁴ **Jurisprudência em Teses, Boletim n. 45**: Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência.

HC 235247/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Julgado em 18/08/2015, DJE 04/09/2015
 HC 270837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 19/03/2015, DJE 30/03/2015

HC 286219/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 18/12/2014, DJE 02/02/2015

HC 271723/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 08/04/2014, DJE 02/05/2014

HC 260330/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 25/02/2014, DJE 10/03/2014

HC 137535/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 21/03/2013, DJE 07/08/2013

HC 248844/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 21/05/2013, DJE 28/05/2013

HC 239965/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Julgado em 18/12/2012, DJE 21/05/2013



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

associativo dotado de tal predicado.

Parcialmente procedente a denúncia, nestes termos, passo à fixação das penas.

Fixo a pena inicial em **05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mínimos.**

A causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, restou comprovada pelas declarações das testemunhas policiais, que foram firmes ao afirmar que o ponto de tráfico no qual ocorreu a abordagem era próximo à Escola Estadual Maud de Sá, bem como pelo mapa do local dos fatos juntado aos autos¹⁵.

Assim, as penas se elevam para **05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínimos.**

Descabida a redução da pena.

No caso em apreço tenho por descabida a redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei de regência, que visa beneficiar aquele incipiente traficante, a quem a norma penal atribuiu menor potencial lesivo na atividade traficante. Isso porque os motivos qualificadores, em termos de desvalor, da conduta

¹⁵Fl. 86



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

são incompatíveis com as formas menos graves da traficância¹⁶, mas não com a hipótese do tráfico qualificado.

Ademais, a grande diversidade de drogas encontradas com o agente também desmerece a medida benéfica.

Finalmente, verifica-se que o acusado já responde a outro processo, como alhures afirmado, o que indica, para os fins da Lei, dedicação a atividades criminosas. Tal situação pode ser aferida, inclusive, pelo envolvimento do agente em diversos inquéritos e processos criminais, com tem entendido o C. Superior Tribunal de Justiça: “Causa de diminuição de pena. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Dedicação à atividade criminosa. Utilização de inquéritos e/ou ações penais. Possibilidade. É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o

¹⁶ **STJ**: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. (1) PRETENSÕES DE UM DOS PACIENTES ANTERIORMENTE EXAMINADAS NESTA CORTE SUPERIOR, NOS AUTOS DO RESP N.º 1249034/MS. TESES PREJUDICADAS. (2) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS E MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(3) APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. (4) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO I, DA LEI DE DROGAS.

(...)

3. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base.

(...)

5. São condições para que o condenado faça jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4.º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Tais requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente; à míngua de qualquer uma dessas condições, como in casu, não é legítimo reclamar a aplicação da minorante. (HC 199.519/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 21/06/2013)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06”¹⁷.

Por tudo isso, descabe a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Ausentes outras condições modificadoras, torno-as definitiva em tais termos.

Observada a natureza das drogas e as condições subjetivas do agente,

17

EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017. Do Informativo de Jurisprudência n. 0596, de 01 de março de 2017, colhe-se a seguinte nota técnica ao v. Acórdão: “A divergência existente no âmbito da Terceira Seção do STJ consiste na possibilidade (ou não) de utilização de inquéritos e processos penais em tramitação para avaliar a possível dedicação do réu a atividades criminosas, de modo a afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Enquanto a Quinta Turma entende plenamente possível a utilização de inquéritos e ações penais em andamento para afastar a causa de diminuição, a Sexta Turma tem entendimento oposto. A Lei 11.343/06 inovou na ordem jurídica em diversos fatores, dentre eles, inseriu uma causa de diminuição de pena para o delito de tráfico de drogas e equiparados, prevista no § 4º do artigo 33. Os requisitos cumulativos previstos para diminuição de pena são: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não se dedicar às atividades criminosas; iv) não integrar organização criminosa. A inserção no ordenamento dessa causa de diminuição teve por escopo diferenciar aquele que não é dedicado a ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de drogas com maior potencialidade lesiva à sociedade. Assim, a regra não deve ser a aplicação da benesse de forma desmedida, mas sua aplicação somente deve ocorrer em casos singulares, quando preenchidos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena. É consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base. Contudo, na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do réu condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Ademais, como os princípios constitucionais devem ser interpretados de forma harmônica, não merece ser interpretado de forma absoluta o princípio da inocência, de modo a impedir que a existência de inquéritos ou ações penais impeçam a interpretação em cada caso para mensurar a dedicação do Réu em atividade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para aquele que responde a inúmeras ações penais ou seja investigado, é equipará-lo com quem numa única ocasião na vida se envolveu com as drogas, situação que ofende o princípio também previsto na Constituição Federal de individualização da pena. Por fim, mister salientar que não se pretende tornar regra que a existência de inquérito ou ação penal obste o benefício em todas as situações, mas sua avaliação para concluir se o réu é dedicado a atividades criminosas também não pode ser vedada de forma irrestrita, de modo a permitir a avaliação pelo magistrado em cada caso concreto”. (grifos nossos)


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

o regime inicial de cumprimento será aquele fechado, na esteira do entendimento do C. Supremo Tribunal Federal a respeito do tratamento a ser dispensado à matéria, particularmente quanto ao regime prisional para início de desconto da pena¹⁸, sendo descabido qualquer benefício em termos de substituição da pena corporal.

Isso posto, **JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE** a denúncia, para o fim de condenar o réu **KEVIN MARTINS PALMEIRA DA SILVA**, qualificado nos autos, às penas de **05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa**, mínimos, por incurso no artigo 33, “caput”, cumulado com artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 bem como para **ABSOLVÊ-LO** da imputação da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/05, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inviável o apelo em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”¹⁹.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento da quantia apreendida nos autos em favor da União, em favor do Funad (art. 62 da Lei n. 11343/2006).

Defiro a restituição do telefone celular apreendido, comprovada a

¹⁸O Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15, e também o RHC N. 132.328-MS, Relator: Min. Dias Toffoli, Informativo 828 STF).

¹⁹AG. REG. NO HC N. 126.879-SP, RELATORA: MIN. ROSA WEBER, Informativo STF 788.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

propriedade. Na inércia, decorridos 90 (noventa) dias, fica autorizada a destruição.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**